

1501509-05.2021.8.26.0567

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Flavio Roberto de Carvalho

Comarca: São Roque

Foro: Foro de São Roque

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 01/04/2022

... trazer consigo para fins de tráfico, sem autorização legal ou regulamentar, a droga proibida, basta para integrar a figura criminosa do tráfico ilícito. Vender, em tema de entorpecente, é uma das condutas típicas, e não "conditio sine qua non" de delito de tráfico ilícito. Nesse sentido: "Apelação - Tráfico de entorpecentes - Materialidade e autoria ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São Roque

Foro de São Roque

1ª Vara Criminal

Av. John Fitzgerald Kennedy, Centro - CEP 18130-510, Fone: 11-2550-5296, São Roque-SP - E-mail: saoroquecr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO

Processo Digital nº:

1501509-05.2021.8.26.0567

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial (Flagrante), Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência - 2214966/2021 - Delegacia de Polícia de Araçariquama, 2214966 - DEL.POL.ARAÇARIGUAMA, 614/21/545 - DEL.POL.ARAÇARIGUAMA, 615/21/545 - DEL.POL.ARAÇARIGUAMA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Thiago Henrique Aparecido da Cruz e outro

Aos 01 de abril de 2022, às 14:30h, em ambiente virtual no programa Microsoft Teams, sob a presidência do MM. Juiz de Direito Dr. Flavio Roberto de Carvalho, comigo Escrevente ao final nomeado, foi aberta a audiência de instrução, debates e julgamento, nos autos da ação entre as partes em epígrafe. Cumpridas as formalidades legais e apregoadas as partes, compareceram o DD. Promotor de Justiça Dr. Renato Augusto Valadão, o réu RUBENS ARCILIO, acompanhado de sua defensora Dra. Cleane Rocha Araujo OAB 67517/MG, a quem foi garantido a entrevista pessoal com o réu, em ambiente virtual, antes do início da audiência; e as testemunhas WASHINGTON JOSÉ FERREIRA CARDOSO, RENATA DE OLIVEIRA, ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA DIAS, CRISTIANO DE OLIVEIRA CAMPOS, CLEBER NOGUEIRA BRIAMONTE. Iniciados os trabalhos, pelas partes foi acordado que no termo somente constara a assinatura digital do magistrado já que o processo é digital, e novamente aceito pelas partes que a audiência seja feita nesta modalidade virtual pelo Microsoft Teams. Pelo MM. Juiz foram colhidos os depoimentos da(s) testemunha(s) Cleber, Washington, Antonio e Renata e realizado o interrogatório do réu Rubens. Pelas partes foi declarado que desistiam da oitiva da testemunha Cristiano. Pelo MM. Juiz foi homologada a desistência da testemunha e declarada encerrada a instrução passando aos debates. Iniciados os debates o Ministério Público se manifestou de forma oral (constante na

gravação). Em seguida o defensor do réu se manifestou também de forma oral (constante na gravação). Encerrados os debates pelo MM. Juiz foi proferida a Sentença: Vistos. RUBENS ARCILIO qualificado nos autos, foi denunciado pelo Ministério Público, pela prática do crime tipificado no artigo 33, "caput" da lei 11343/06 porque nas circunstancias de tempo e local descritas na inicial, guardava e tinha em depósito para comercialização a terceiros, 32 tijolos de maconha, 05 cigarros de maconha, e 04 papelotes de maconha, drogas que determinam dependência física e psíquica, sendo certo que agiam sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. Acompanhou a denúncia o inquérito policial (fls.01/197) e documentos, onde se destaca: auto de prisão em flagrante (fls.01/12), boletim de ocorrência (fls.13/17), auto de exibição e apreensão (fls.19/21), exame químico toxicológico (fls.79/83), depósito judicial (fls.134) , laudo de arma de fogo e munições (fls.144/156), laudo motocicleta (fls.161/164), laudo celular (fls.165/170), laudo objetos (fls.171/180), laudo químico toxicológico (fls.284/286) A denúncia foi recebida em 23 de setembro de 2021 (fls.205/206), o réu foi citado e ofertou Defesa (fls.224/233), prosseguindo a instrução com as oitivas de testemunhas e colheita do interrogatório. Em debates finais, o Ministério Público insistiu na condenação com afastamento do redutor. A Defesa arguiu em preliminar que a policia ingressou na residência sem autorização judicial, e no mérito insistiu na improcedência diante da fragilidade probatória. É o relatório. DECIDO. Quanto a preliminar arguida pela Defesa, o réu estava cometendo trafico de drogas, na conduta armazenar, delito permanente e que independe de mandado de busca, sendo que o próprio réu admitiu que autorizou a entrada dos policiais em sua residência, e entregou outra quantidade menor, o que leva ao afastamento da preliminar arguida. No mérito, a materialidade está comprovada a saciedade pelo auto de prisão em flagrante (fls.01/12), boletim de ocorrência (fls.13/17), auto de exibição e apreensão (fls.19/21), exame químico toxicológico (fls.79/83), depósito judicial (fls.134) , laudo de arma de fogo e munições (fls.144/156), laudo motocicleta (fls.161/164), laudo celular (fls.165/170), laudo objetos (fls.171/180), laudo químico toxicológico (fls.284/286), corroborado pela prova oral coligida. Quanto a autoria, o acusado disse que a policia chegou e já estava com as drogas, e disse que iriam levar todos, e que para não prejudicar a esposa, e ficou com medo e assumiu o trafico, sendo que teve o celular apreendido, e que estava na churrasqueira, e não se recorda das mensagens. Entregou drogas que estavam na residência, e que eram para uso pessoal. A contabilidade estava na borracheira. Os policiais encontraram a droga antes de baterem no portão de sua casa. Não conhecia os policiais. A negativa do réu se encontra isolada no contexto probatório. De fato, os policiais ao apurarem denuncia anônima acabaram obtendo êxito na diligencia, com apreensão de grande quantidade de drogas, além de contabilidade, e celular o qual apos autorização judicial, foi periciado, encontrando-se diversas mensagens do réu com outros indivíduos a respeito de drogas, e da abordagem policial. Realmente Cleber disse que receberam denuncia anônima, de que no local dos fatos havia grande quantidade de drogas que tinha acabado de chegar, e abordaram um individuo sendo que o outro correu, e ele disse que a pessoa que correu era seu cunhado, e que abandonou a motocicleta que foi apreendida e que não tinha identificação, e ele disse que possuía armas e simulacros, e conduziu a policia ate o local, e quem, fazia o trafico era o vizinho de nome Rubens. Na casa ele entregou as armas, e um saco de munições com vários calibres, e ele disse que guardava no mato. Ele tinha enterrado as espingardas e ele desenterrou e entregou as mesmas. Abordaram o Rubens na rua, e indagou a respeito dos fatos, inclusive o acusado confessou e mostrou uma mochila com grande quantidade de maconha, sendo que na casa foram apreendidos embalagens e uma balança. A mochila estava no quintal, próximo a uma bananeira, sendo que esta informação veio na denuncia anônima, bem como, uma caixa de papelão com tijolos de maconha. Não conhecia o réu, e ele tinha um mandado de prisão em aberto o trafico. O acusado disse que pegou esta droga em um posto na Castelo Branco. O terreno e grande e não da para saber a quem pertence, e tem uma construção nos fundos. Disse que a rua da abordagem se encontra a fls. 276, e abordaram o réu um pouco abaixo do muro de cor branca. A droga estava no fundo da

propriedade perto da mata e ao lado, atrás da borracharia, foi onde o Tiago desenterrou as armas. A parte da frente da residência do réu é murada, mas os fundos é cercado. Jose Álvaro que seria cunhado de Thiago teriam fugido. O réu foi abordado na rua, e confessou os fatos, e mostrou que as drogas prontas a venda, estavam em um cano de esgoto, e ele levou a equipe ate o local onde estavam as drogas. Não se recorda se a embalagem, e balança estavam na parte da churrasqueira, e dentro da mesma, encontraram um celular, que o réu dispensou pois estava com muitos contatos, e a esposa do réu disse que fazia bolos para vender. Washington reiterou o depoimento de Cleber, acrescentando que Tiago disse que Álvaro seu cunhado e que correu atuava com Rubens, sendo que ele disse possuir armas, e entregou munições e armas incompatíveis, e ele disse que tinha enterrado outro armamento, que foi desenterrado e entregue, sendo que ao saírem encontraram Rubens que foi indicado por Tiago, sendo que o acusado confessou, e levou ao local onde estavam as drogas, e também levou a equipe na residência, onde apreenderam embalagens, balança de precisão, e conduziram as partes e a motocicleta que seria do Álvaro para a delegacia. Não conhecia os réus. Tinha uma quantidade em uma caixa de papelão e outra em uma bolsa. Achariam a droga na bananeira, pois havia a indicação na denuncia, mas não conseguiriam encontrar as armas se Tiago não tivesse mostrado o local. Não se recorda o local onde apreendeu o celular. A residência do réu é murada, mas o terreno em volta não é murado, mas sim fechado com cerca. As embalagens foram encontradas em uma residência, uma espécie de edícula ao lado da casa, sendo uma residência simples, e no primeiro cômodo havia uma televisão ligada, e do lado que parecia ser uma sala, foi onde encontraram os objetos. De imediato o réu confessou que este produto era para embalar drogas. Onde foram encontrados os tijolos de maconha, estavam na bananeira. A pessoa que fugiu estava junto com Thiago na via publica, e Álvaro se evadiu pelo matagal, e não foi encontrado, e Tiago disse que ele era responsável pelas drogas juntamente com Rubens. O acusado autorizou a entrada na casa, onde foi apreendida uma pequena quantidade já embalada para venda e que foi entregue pelo próprio réu. Antônio, disse que não estava com o réu, e ficou sabendo uns dias depois, pois tinha um bolo para retirar com a esposa dele, e ela disse que ele foi preso por trafico de drogas. A esposa não entrou em detalhes, e não conhecia a bananeira, e o local é rural. Já comprava bolo ha dois anos da esposa do réu. Às vezes encontrava o réu no local, e ele fazia carretos. Renata disse que a esposa do réu trabalha com bolos, e o réu já fez frete, e também trabalhou em borracheira, e não conhecia a propriedade, sendo que não sabe onde ficava a bananeira. Depois da prisão a esposa do réu mudou do local. Vale mencionar que nenhuma restrição merecem os depoimentos dos guardas municipais mormente quando suas declarações vêm corroboradas por outros elementos de prova e também quando não levantada qualquer suspeita fundada e demonstrada. Nesse sentido: "não existe motivo algum a ensejar a desvalia do depoimento policial. Seria um contrassenso credenciar o Estado alguém a atuar em seu nome e, depois, negar-lhe crédito, quando, perante o mesmo Estado-Juiz, viesse relatar seus atos de ofício. Por isso, totalmente superada a tese do desprestígio do relato policial na moderna jurisprudência. O agente de segurança é testemunha como as demais. Submete-se a compromisso e terá seu depoimento avaliado no cotejo de todas as provas sem plus-valia, mas também sem preconceito. "(TACRIM-SP JUTACRIM 30/221). Com efeito, conforme amplamente decidido, "a simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita" (STF, RTJ 68/54), entre outros arestos (RT 530/372, 411/266, 445/382 e RJTJESP-LEX 136/476). Ademais, seria um contrassenso o Estado credenciar pessoas para a função repressiva e depois lhe negar crédito quando dão conta de suas diligências (RT 417/94, 486/351, 771/565 e 772/682). Por isso, eventuais pequenas contradições entre os depoimentos prestados em Juízo, se comparados entre si e com os da fase administrativa, são naturais e reforçam a ausência de prévia combinação entre as pessoas ouvidas, ou qualquer sanha obstinada em falsa incriminação. Observa-se ainda que, "pequenas dissonâncias na prova oral não têm o condão de fazer esboroar o arcabouço probatório. O importante

é constatar-se a concordância nos pontos essenciais, desprezando-se eventuais discrepâncias, em pontos secundários, que são fruto das imperfeições do psiquismo

humano" (JUTACRIM 95/262). "O depoimento do policial é tão válido como outro desde que insuspeito e capaz de infundir, pelo seu conteúdo, incredibilidade. Por outro lado, nos termos do art. 202 do CPP, se toda pessoa pode ser testemunha, sem qualquer dúvida que os agentes podem testemunhar sobre o que viram e sentiram no cumprimento da missão. Se por/acaso outras pessoas havia no local da diligência, cumpre à defesa arrolá-las como testemunhas. Também pequenas divergências que não atingem a substância do fato não são suficientes para ilidir aprova" (RT574/401). "PROVA CRIMINAL - Testemunha - Hipótese de tóxico - Depoimento prestado por policial - Validade - Servidores que não estão impedidos de depor - Testemunhas, ademais, que não foram sequer contraditados em Juízo - Recurso provido. Os policiais militares, como qualquer outra pessoa, não estão impedidos de depor e seus testemunhos não podem e não devem ser, de modo algum, de forma apriorística, considerando suspeitos, apenas em decorrência da condição de policial, (relator Ângelo Galluci - Apelação Criminal nº 153.694-3-São Paulo-26.09.94)". "DEPOIMENTO DE POLICIAIS. MEIO PROBATÓRIO VALIDO. - O depoimento de policiais pode servir de referência ao juiz na verificação da materialidade e autoria delitivas, podendo funcionar como meio probatório válido para fundamentar a condenação, mormente quando colhido em juízo, com a observância do contraditório, e em harmonia com os demais elementos de prova". (STJ, 5.a Turma, HC 110869/SP, Rei. Ministro Arnaldo Esteves Lima, v.u., j. 19.11.2.009; pub. DJe de 14.12.2.009). Não trouxe o acusado qualquer prova ou elemento a contrariar a idoneidade dos depoimentos policiais. Além dos depoimentos policiais que sequer conheciam o réu, tem-se o laudo do celular com as mensagens a respeito de drogas, que soma-se a perícia de contabilidade de tráfico, além de embalagens usadas para acondicionamento de drogas. Pontua-se ainda que a balança de precisão apreendida era usada para a pesagem de drogas, tanto que fotografia da mesma com entorpecente foi encontrada no laudo pericial do celular. Estranho o réu alegar que os instrumentos eram usados pela esposa, que ate o momento não ingressou nos autos pleiteando a liberação, o que ocorreria, se realmente a versão fosse verossímil. Não se olvide que grande quantidade de drogas com alto valor comercial foi encontrado na casa do réu, sendo dispensando a necessidade de mandado de busca, ate porque o tráfico é crime permanente, no qual o réu estava em flagrante delito. O acusado não conseguiu afastar os laudos periciais de objetos apreendidos consigo, tampouco a localização das drogas, e as mensagens, sendo que restou mais do que demonstrado que estava armazenando as drogas, preenchendo a elementar do tipo penal. Também não conseguiu afastar a diligencia policial de localização das drogas em sua propriedade, tampouco conseguiu explicar a origem do dinheiro apreendido consigo, ou seja, a prova é robusta e farta a apontar a autoria do acusado no delito de tráfico de drogas, nas condutas manter em depósito, guardar e armazenar. Em suma, os depoimentos colhidos, à luz do contraditório e as demais provas acostadas aos autos, somadas a efetiva apreensão de droga, evidenciam a realidade do tráfico exercido pelo réu. Vale citar: "Adquirir, guardar ou trazer consigo, sem autorização legal ou regulamentar, substância entorpecente, são condutas comuns aos delitos de tráfico ilícito e uso indevido, do que resulta, pelo princípio da exclusão, quando não se tratar de uso indevido, reconhecer o narcotráfico. Caracteriza o delito de tráfico ilícito de substância entorpecente trazer consigo, sem autorização legal ou regulamentar, maconha e cloridrato de cocaína, em doses unitárias, de pequenos embrulhos, embalagem usual do varejo das drogas" (TJRJ - AC 1.185/93 - Rel. Enéas Machado Cotta - TDTJRJ 23/288). A lei pune o tráfico ilícito de entorpecente em qualquer de suas condutas, típicas e exclusivas. Em tema de entorpecente, a conduta de guardar, ter em depósito, trazer consigo para fins de tráfico, sem autorização legal ou regulamentar, a droga proibida, basta para integrar a figura criminosa do tráfico ilícito. Vender, em tema de entorpecente, é uma das condutas típicas, e não "conditio sine qua non" de delito de tráfico ilícito. Nesse sentido: "Apelação - Tráfico de entorpecentes - Materialidade e autoria devidamente demonstradas nos autos, pela prova documental e oral - Conjunto probatório suficiente à condenação - Pleito visando a desclassificação para o delito de porte de drogas - Impossibilidade - A diversidade, a forma de acondicionamento da droga, sua quantidade, assim como as circunstâncias da

apreensão, demonstram, à evidência, que o entorpecente se destinava ao tráfico - Pena e regime corretamente fixados - Sentença mantida - Apelo improvido. (Apelação nº 0005711-21.2009.8.26.0050, TJ/SP, 16 Câmara de Direito Criminal, negaram provimento, v.u, data julgamento 01/03/2011, relator Des. Borges Pereira) "A inversão do ônus da prova, uma vez que o trabalho acusatório demonstrou suficientes indícios de autoria, além de prova cabal da materialidade do crime, incumbindo, pois, às defesas indicarem fatos que afastasse, inequivocamente, os seguros indicativos da participação das acusadas no crime. "Para a formação de um juízo de certeza razoável sobre o comércio de entorpecentes, não é necessária prova efetiva do tráfico. O conjunto de indícios e elementos que cercam o agente infrator podem fornecer o material de convencimento da traficância. Inexige-se, portanto, prova flagrancial do comércio ilícito, bastando, como já dito, elementos indiciários, como 'confissão extrajudicial, a quantidade e qualidade do material apreendido, a conduta e os antecedentes do agente, bem como as circunstâncias da prisão' (art. 37, LT), ser substância oriunda de área e rota de comércio ilícito etc. Erigir-se, como regra, a necessidade de prova direta da finalidade comercial da substância entorpecente em poder do acusado, para fazer incidir o art. 12, por um lado é inviabilizar o combate ao tráfico e ao mesmo tempo dar ensejo à disseminação do comércio ilícito. Além de sob o ponto de vista jurídico constituir-se numa teratologia." (RODRIGUES, João Gaspar. Tóxicos: Abordagem crítica da Lei nº 6.368/76. Campinas: Bookseller, 2001. p. 157). "APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO-DE ENTORPECENTES - ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS - RESPEITO AO PRINCÍPIO DO IN DÚBIO PRO REO - PRETENSÃO IMPROCEDENTE - DEPOIMENTO POLICIAL CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA - CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE - RECURSO IMPROVIDO. Não há falar em absolvição com base na negativa de autoria isolada nos autos, quando os demais elementos de prova, como depoimento prestado por policial dão suporte à condenação do réu. O testemunho prestado por policial é válido e tem o mesmo valor relativo que qualquer outra prova que se traga aos autos, porquanto são revestidos de presunção de veracidade até que haja prova em contrário. (Apelação Criminal - Reclusão - N. 2010.002225-8 - Três Lagoas - Relator - Des. Claudionor Miguel A. Duarte - Julgamento: 8/3/2010) Apelação - Tráfico DE ENTORPECENTES - CRIME DE AÇÃO MÚLTIPLA - Interceptação Telefônica PROVIMENTO PARCIAL. Mantém-se a condenação do acusado pelo tráfico de entorpecentes quando devidamente caracterizadas a autoria, a materialidade e tipicidade. [...]. O crime de tráfico de entorpecentes é de natureza múltipla, caracterizando-se quando o agente pratica um ou mais dos núcleos do tipo previsto no art.33 da Lei 11.343/06. (AC nº 1.0384.07.053086-8/001 - Rei. WALTER PINTO DA ROCHA - Data da Publicação: 04/04/2008). É certo que para a caracterização do tráfico de entorpecentes não é indispensável a prova do ato de comércio, podendo ser ele deduzido de elementos carreados, como as circunstâncias da prisão, a quantidade do entorpecente, o local da infração, etc. Nesse sentido, sobre o valor probatório dos indícios, cita-se a lição de Julio Fabrinini Mirabete, constante no acórdão do ilustre Relator Borges Pereira(Apelação nº 0005711-21.2009.8.26.0050, TJ/SP, 16 Câmara de Direito Criminal, negaram provimento, v.u, data julgamento 01/03/2011), a saber:(...) tanto mais forte o indício quanto mais íntima sua relação com o fato, não havendo princípios inflexíveis sobre o valor da prova indiciária no processo (...) diante do sistema da livre convicção do juiz, encampado pelo Código, a prova indiciária, também chamada circunstancial, tem o mesmo valor das provas diretas, como se atesta na exposição de motivos, em que se afirma não haver hierarquia de provas por não existir necessariamente maior ou menor prestígio de uma com relação a outra. Assim, indícios múltiplos, concatenados e impregnados de elementos positivos de credibilidade são suficientes para dar base a uma decisão condenatória, máxime quando excluem qualquer hipótese favorável ao acusado, (in Código Penal Interpretado - Ed. Atlas - SP -1999 - pág. 532). (citado no corpo do acórdão da apelação 0005711-21.2009.8.26.0050, TJ/SP, 16 Câmara de Direito Criminal, negaram provimento, v.u, data julgamento 01/03/2011, relator Dês. Borges Pereira) Desta forma a procedência da ação é de rigor. Passo a dosimetria da pena. Atento ao disposto no artigo 42 da Lei 11343/06 e art.59 do Código Penal, verifico que a quantidade de droga era significativa, e renderia lucro considerável, e com grande valor econômico o que mostra a desvalia da conduta,

sendo que este fator, pode ser usado na fixação da pena base. Nesse sentido: "HABEAS CORPUS. TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. DOSIMETRIA. PENA BASE. FIXAÇÃO ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. NATUREZA E QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDAS. ART. 42 DA LEI 11.343/06. EXASPERAÇÃO DA REPRIMENDA. FUNDAMENTAÇÃO

CONCRETA E IDÔNEA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL AUSENTE. 1. Em se tratando de crime de tráfico de drogas, como ocorre na espécie, na fixação das penas, deve-se considerar, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do CP, a natureza e a quantidade da substância entorpecente, consoante o disposto no art. 42 da Lei 11.343/06. 2. Verificado que foi levada especialmente em consideração a natureza e a quantidade da substância encontrada - 693 g (seiscentos e noventa e três gramas) de cocaína -, não há que se falar em constrangimento ilegal quando a sanção básica foi fixada apenas seis meses acima do mínimo legalmente previsto, vez que apontados fundamentos concretos a justificar maior reprimenda. Ordem denegada" (STJ - HC nº 231882/SP rel. Min. Jorge Mussi j. 20/06/2012). "A dosimetria da pena, além de não admitir soluções arbitrárias e voluntaristas, supõe, como pressuposto de legitimidade, adequada fundamentação racional, revestida dos predicados de logicidade, harmonia e proporcionalidade com os dados empíricos em que se deve basear. 2. Idônea a exasperação da pena-base com fundamento na natureza das substâncias traficadas, consoante preconiza o art. 42 da Lei 11.343/2006 c/c art. 59 do Código Penal. 3. A avaliação do quantum de atenuação da pena, à míngua de previsão legislativa dos parâmetros a serem considerados, sujeita-se ao livre convencimento motivado do julgador, observado o limite máximo de redução, as circunstâncias do caso e os princípios da proporcionalidade e razoabilidade" (STF - RHC 129951 / PR Rel. Min. Teori Zavascki Segunda Turma DJe 08/10/2015.). Assim, reconhecendo este fator, a apontar a culpabilidade acima da media, ate porque se as drogas apreendidas fossem divididas em porções de 1 g, mais de 21 mil porções seriam separadas, a um preço de R\$ 5,00, já da para se ter a noção do lucro do acusado, reforçando a necessidade desta ponderação para a fixação da pena que fica em 3/5 acima do mínimo. Presente a agravante da reincidência especifica, o réu já foi condenado por trafico de drogas delito equiparado ao hediondo, e novamente incide na mesma conduta, o que eleva a pena em 1/3, totalizando, 10 anos e 08 meses de reclusão e pagamento de 1066 dias-multa. Ausentes atenuantes, causas de aumento ou de diminuição de pena não se aplicando o redutor já que o réu é reincidente. Fixo a míngua de outro elemento o dia -multa no mínimo legal. Deixo de substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos para o réu, por não ser permitido pela lei 11343/06, e por partilhar do entendimento da inviabilidade do acolhimento de tal benefício em relação ao crime de tráfico ilícito de entorpecente. Realmente o delito de trafico envolve o que há de pior no ser humano em relação ao seu semelhante, lucrando-se e aproveitando-se da fraqueza humana, destruindo dependentes e familiares. Na verdade a droga se constituiu no principal mote da violência, sustentando toda uma cadeia criminosas, com lucro fácil, não sendo possível, premiar o traficante que tanto mal causa a terceiros com a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Pontua-se ainda que a pena supera o limite legal. Saliento que não seria possível a aplicação da substituição tendo em vista a vedação do inciso III do artigo 44 do Código Penal, já que possui circunstância judicial negativa, além do total de pena aplicado a espécie. Incabível a suspensão condicional da pena, pelas mesmas razões. "RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA.

IMPOSSIBILIDADE. VEDAÇÃO LEGAL EXPRESSA. RECURSO PROVIDO. 1. Não tem direito à suspensão condicional da pena quem é condenado por crime de tráfico de drogas, positivado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, por expressa vedação do art. 44, caput, dessa lei. (...)" (STJ, REsp 1373032/DF, 6ª Turma, Min. Rogério Schietti Cruz, jg. 17/12/2015, DJe 11/03/2016) Levando-se em consideração a quantidade de drogas, e o alcance significativo de usuários, a indicar uma maior reprovabilidade da conduta, somado as circunstâncias judiciais negativas já reconhecidas, e pontuado-se o bem jurídico protegido, além da pena aplicada, fixo o regime inicial fechado para inicio de cumprimento de pena, ressaltando que o réu é reincidente e estava foragido já que possuía condenação anterior com transito em julgado. Mesmo considerando o tempo da prisão, ainda não atingiu limite suficiente para alteração

do regime. Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva do Estado constante na denúncia, para CONDENAR como incurso no artigo 33 caput da lei 11343/06 o réu RUBENS ARCILIO a pena privativa de liberdade de 10 (dez) anos e 08 (oito) meses de reclusão em regime inicial fechado além do pagamento de 1066 (um mil e sessenta e seis) dias-multa cujo valor unitário consiste em um trigésimo do salário mínimo mensal vigente no dia dos fatos (art. 49, § 1º, do mesmo Código), a partir do qual será atualizado, em conformidade com o art. 49, § 2º, primeira parte, do aludido Estatuto Penal (cfr. SEBASTIÃO DA SILVA PINTO em RT 645/255-262; TACRIM em RT 682/335, 782/614, JUTACRIM 95/45; STJ em RE 41.438-5-SP, 5ª T., Rel. Min. ASSIS TOLEDO, em D.J.U. 17/10/94, pág. 27.906; STJ - Embargos de Divergência em Recurso Especial nº 91.003-RS - 3ª S - Rel. Min. Gilson Dipp - J. 13.12.99 - DJU 21.02.2000; STJ, RE 22.497/8-SP, 5ª T., Rel. Min. José Dantas, DJU 13.10.1992, p. 17.700 etc).. Custas pelo acusado nos termos da lei. Não verifico condição a alterar a prisão, que permanece hígida, contemporânea e necessária, ate porque o réu estava foragido com condenação com transito em julgado, bem como, em liberdade reiterou na conduta, com grande quantidade de drogas, o que mostra a insistência da conduta delituosa, e a certeza da impunidade e da frustração da aplicação da lei penal, fomentando a violência e a guerra urbana o que mostra o risco a ordem publica. A questão de possuir filho menor de idade não leva a liberdade, ate porque não demonstrou que seria o principal provedor, tanto que o mesmo encontra-se com a genitora e sob cuidados da família, não existindo qualquer elemento a indicar desamparo. Assim, por todos os lados não se constata alteração das condições, estando presentes os requisitos da prisão, o que leva ao indeferimento do recurso em liberdade. Expeça-se novo mandado de prisão em desfavor ao réu. Nesse sentido: "HABEAS CORPUS alegação de falta de fundamentação da r. sentença que indeferiu o direito de recorrer em liberdade, tendo se baseado tão somente na gravidade concreta do crime inoccorrência. HABEAS CORPUS presença do fumus comissi delicti no auto de apreensão e prova oral que indica a subtração mediante violência e grave ameaça, indicando o paciente como autor presença do periculum libertatis pelo fato do paciente não ter vínculo com o distrito da culpa; praticar o crime com alta reprovabilidade e periculosidade; não haver prova de que exerce atividade lícita prisão preventiva que não ofende o princípio da presunção de inocência fato de ser primário e sem antecedentes, bem como possuindo residência fixa, não vedam a possibilidade da prisão cautelar. HABEAS CORPUS desproporcionalidade da medida remédio heroico que não se presta a exercício de futurologia. HABEAS CORPUS pandemia COVID-19 paciente que não compõe grupo de risco efetivo isolamento social - indefere-se o processamento. Observa-se que o paciente praticou crime de roubo majorado, com emprego de grave ameaça à pessoa. A prática de crimes com violência ou grave ameaça contra a pessoa geram desassossego e intranquilidade popular. A circunstância de alguém praticar crime desta espécie e ser solto em seguida causará descrédito na Justiça, além de estimular à prática de novos crimes análogos, bem como levará a população a buscar resolver os problemas de segurança por outros métodos, como fazer justiça com as próprias mãos. Desta forma, necessária a custódia do requerente para garantia da ordem pública para estes casos, a menos que ocorra excepcionalmente prova em contrário, não existente nos autos.(Habeas Corpus Criminal nº 2132867-25.2020.8.26.0000, TJSP, relator Desembargador Lauro Mens de Mello, 30/06/2020).“Agravamento regimental em habeas corpus. Homicídio qualificado (CP, art. 121, § 2º). Processual Penal. Prisão preventiva (CPP, art. 312). Falta de fundamentação para justificar a medida extrema. Não ocorrência. Garantia da ordem pública. Gravidade em concreto da conduta e real periculosidade do agravante. Risco real de reiteração delitativa. Fuga do distrito da culpa. Custódia preventiva devidamente fundamentada. Regimental não provido. 1. Mostra-se idôneo o decreto de prisão preventiva quando assentado na garantia da ordem pública, ante a periculosidade do agente, evidenciada não só pela gravidade in concreto do delito, em razão do seu modus operandi, como também pelo risco real da reiteração delitativa. 2. Consoante o entendimento do Supremo Tribunal Federal, “a evasão após a prática delitativa é fundamento idôneo para a segregação cautelar para resguardar a aplicação da lei penal” (HC nº 90.162/RJ, Primeira Turma, Relator o Ministro Ayres Britto, DJe de 29/6/07). 3. Agravamento regimental ao qual se nega provimento” (2 STF HC 127578

AgR/SP rel. Dias Toffoli j. 25.08.2015); "A prisão cautelar justificada no resguardo da ordem pública visa prevenir a reprodução de fatos criminosos e acautelar o meio social, retirando do convívio da comunidade o indivíduo que diante do modus operandi ou da habitualidade de sua conduta demonstra ser dotado de periculosidade". "A prisão preventiva mostra-se necessária para a garantia da ordem pública, tendo em vista a periculosidade do paciente, evidenciada por sua personalidade delitiva, já que foi condenado por roubo e estelionato (reincidência), responde por furto e cometeu o delito em questão quando estava em livramento condicional"(STJ HC 246855 / MG rel. Min. Marilza Maynard j. 21.02.2013) "A prisão

cautelar se mostra suficientemente motivada para a preservação da ordem pública, tendo em vista a periculosidade do paciente, verificada pelo modus operandi mediante o qual foi praticado o delito. Precedentes. II A possibilidade concreta de fuga também mostra-se apta a embasar a segregação cautelar para assegurar a aplicação da lei penal. Precedentes. III Esta Corte já firmou entendimento no sentido de que, permanecendo os fundamentos da custódia cautelar, revela-se um contrassenso conferir ao réu, que foi mantido custodiado durante a instrução, o direito de aguardar em liberdade o trânsito em julgado da condenação. Precedentes. IV - Ordem denegada" (0 STF HC 114536/MG Rel.Min. Ricardo Lewandowski DJU 05.12.2012.). Autorizo assegurada a contraprova e desde que não providenciado, a incineração da droga apreendida independente do trânsito em julgado. Também determino o perdimento do dinheiro já que não comprovada origem idônea. Por fim, determino a destruição dos demais objetos utilizados para o trafico de drogas, inclusive o aparelho celular. Oportunamente, após o trânsito, lance-se o nome do réu Rol dos Culpados e providencie-se o necessário para o efetivo cumprimento da sanção imposta, comunicando a Justiça Eleitoral e o IIRGD, remetendo-se após ao arquivo com as cautelas de praxe. Sentença publicada em audiência. Saem os presentes intimados. Pelo Ministério Público foi dito que desistia do prazo recursal. Pela Defesa e pelo réu foi dito que interpunham recurso. Pelo MM Juiz foi decidido: Homologo a desistência do recurso ministerial e recebo o recurso da Defesa saindo intimada para apresentar razões no prazo legal.Com a juntada manifeste-se o Ministério Público, e apos encaminha-se ao Tribunal de Justiça com nossas homenagens. Saem os presentes intimados. Nada mais. Eu, Guilherme Parra Magri, digitei.

O arquivo de vídeo e áudio com a gravação da presente audiência, encontra-se disponível às partes no link:

https://tjssp-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/gmagri_tjssp_jus_br/EUI1zfLAQkpHHkYrCghXY08Bhbu_FZuIraFC28eRkPL9gg?e=5qN3F8

MM. Juiz: assinado digitalmente